

1504529-94.2022.8.26.0073

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

Comarca: Avaré

Foro: Foro de Avaré

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... sentido, decisão da E. Corte Bandeirante:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Impetração visando a absolvição pela fragilidade probatória Pedido final de desclassificação ou substituição da pena.

IMPOSSIBILIDADE. Presentes a autoria e a materialidade - Reconhecimento do tráfico pelas circunstâncias da ocorrência - Usuário também pode ser traficante Guardas civis que visualizaram o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Avaré

Foro de Avaré

1ª Vara Criminal

Rua Abílio Garcia, 527, Avare-SP - cep 18706-047

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1504529-94.2022.8.26.0073 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504529-94.2022.8.26.0073

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2158158/2022 -

DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 25488956 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2158158 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2158158 - DISE- DEL.SEC.AVARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENDINER LUIZ CORREA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

VISTOS.

HENDINER LUIZ CORREA e MARCELO BUENO DA SILVA, já qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 c.c. artigo 29 do Código Penal, sob a acusação de que, na tarde de 09 de junho de 2022, por volta das 17 horas, na Praça João Valente, número 2961, Centro, nesta cidade e Comarca de Avaré, traziam consigo e tinham em depósito 08 (oito) porções de maconha, com peso aproximado de 88,43g (oitenta e oito gramas e quatrocentos e trinta miligramas), conforme auto de constatação provisória a fls. 29/32 e laudo de exame químico-toxicológico às fls. 97/99, substâncias que causam

dependência, o que faziam em desacordo com norma legal ou regulamentar (portaria 344/98 SVS/MS).

Auto de prisão em flagrante e demais peças do inquérito policial a fls. 01/111. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 68/73). Mandados de prisão cumpridos a fls. 88/90 e 92/94. Por decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de Habeas Corpus, a prisão preventiva foi substituída pelas medidas cautelares em relação ao réu Hendiner Luiz Correa (fls. 131/135). Alvará de soltura cumprido a fls. 151/154. Devidamente notificados a fls. 155 e 165, os réus apresentaram defesa preliminar a fls. 166/171. Posteriormente, sobreveio decisão do C. Superior Tribunal de Justiça revogando a prisão preventiva de Marcelo Bueno da Silva em sede de Habeas Corpus (fls. 179/187). Alvará de soltura cumprido a fls. 206/209. Não sendo o caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 31 de agosto de 2022, oportunidade na qual também foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 188/190). Em audiência, foram inquiridas duas testemunhas de acusação e os réus interrogados (fls. 225/226 e gravações audiovisuais).

Em sede de alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia (fls. 229/233). A douta Defesa dos réus pugnou pela desclassificação do crime para a figura do art. 28 da lei 11.343/06 e, ainda, em caso de eventual condenação, pela fixação da pena em seu patamar mínimo legal, pela aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da lei de Drogas, bem como pela fixação do regime aberto e substituição da pena por restritivas de direitos e pelo direito de recorrer em liberdade (fls. 236/241).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Segundo a inicial acusatória, "na data dos fatos HENDINER e MARCELO traziam consigo oito porções de maconha para venda e entrega ao consumo de terceiros. De fato, os policiais militares tinham informações de que traficantes deixavam entorpecentes enterrados escondidos próximo à linha férrea, sendo que para lá se dirigiram e ao visualizarem os acusados, notaram quando estes dispensaram alguns objetos. Efetuada a abordagem, mediante busca pessoal foram apreendidas as oito porções de entorpecente acima mencionadas e, ainda, R\$ 160,00 (cento e sessenta reais) com MARCELO e R\$ 60,00 (sessenta reais) com HENDINER, em espécie e notas diversas. A quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento e as circunstâncias da prisão indicam que os entorpecentes se destinavam ao fornecimento e entrega ao consumo de terceiro".

Pois bem, examinada a questão à luz da prova produzida, é forçoso reconhecer que a denúncia procede integralmente.

A materialidade do delito restou configurada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), boletim de ocorrência a fls. 11/13, auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, laudo de constatação provisória a fls. 29/32, fotografias a fls. 41, 44 e 48, laudo toxicológico a fls. 97/99, bem como por toda a prova oral produzida em juízo.

A autoria delitiva, de igual modo, também restou incontestada e recai sobre os réus. A testemunha de acusação Rodolfo José Coelho, policial militar, em juízo, contou "que o local é conhecido pela venda de drogas e que, na ocasião, se depararam com os réus, os quais ao perceberem a presença da polícia dispensaram um objeto ao chão. Disse que ambos os réus eram conhecidos dos meios policiais. Contou que nas proximidades do local dos fatos, houve pretérita operação da Polícia Civil que encontrou drogas enterradas com o auxílio de um cão farejador. Falou que os réus tinham as mãos sujas de terra no momento da abordagem e que haviam recebido notícias de usuários de que os réus enterravam as drogas. Informou que os acusados estavam juntos e ambos jogaram drogas quando avistaram a viatura".

A testemunha Leandro Sebastião de Almeida, policial militar, judicialmente, reprisou a assertiva de seu colega, acrescentando "que os réus se deslocavam da linha férrea sentido à praça, local conhecido pelo tráfico de drogas e que o dinheiro apreendido era em notas diversas".

O réu Marcelo, em seu interrogatório judicial, negou a prática dos fatos que lhe são imputados. Disse "que havia saído de casa para comprar leite e gás e acabou

sendo abordado junto com outros indivíduos desconhecidos".

O réu Hendiner, em sede de interrogatório judicial, também negou a prática da traficância. Disse "que não sabe porque está sendo acusado, que não tem problemas com esses policiais, que o dinheiro que foi encontrado era seu".

Pois bem, as provas colhidas em juízo apontam para a condenação dos réus, eis que a finalidade de tráfico está evidenciado pelas circunstâncias da apreensão, quantidade e modo de acondicionamento do entorpecente.

Com efeito, verifico que as versões ofertadas pelos réus não encontram respaldo nas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não passam de uma tentativa infrutífera de eximi-los da grave imputação que lhes é feita, o que é plenamente lícito, mas insuficiente para desfigurar a tese acusatória que vem amparada pelo depoimento dos policiais e prova da materialidade. Ademais, da fase inquisitiva à judicial, os depoimentos prestados pelos agentes foram firmes e seguros, não se vislumbrando qualquer interesse em acusar ou prejudicar os réus, merecendo plena credibilidade a versão por eles ofertada. Não se pode conceber a justificativa rasa de que os policiais permanecem perseguindo cidadãos e atribuindo-lhes a propriedade de quantia tão grande de entorpecente com o único fim de prejudicar a ré. Nesse sentido:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846) (g.n.).

Ademais, para efeito da tipificação do delito em questão, além da quantidade do entorpecente, outras circunstâncias devem ser observadas, tais como a forma como estavam embaladas, natureza da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes dos agentes. In casu, o modo e a quantidade de drogas apreendidas, além da quantidade em dinheiro, revelam, de maneira indubitável, que seu fim era a mercancia ilícita.

Ressalto, ainda, que para caracterização do crime de tráfico de drogas não é indispensável que o agente seja flagrado realizando o comércio de drogas. O tipo penal do art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006 é de conteúdo múltiplo e define crime de perigo abstrato. Dessa maneira, basta a conduta de guardar, ter em depósito ou trazer consigo a droga, desde que evidenciada a finalidade de entrega a terceiro, para que o crime em questão reste caracterizado. E, no caso, essa finalidade está bem evidenciada, tornando-se incabível falar em desclassificação para o crime de posse de drogas. Nesse sentido:

"... não é indispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, bastando o conjunto de indícios e presunções que, saliente-se, são claros e convergem contra o acusado, não podendo o juiz desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas, representando aquelas o conhecimento adquirido pela prática e observação do cotidiano." (TJSP, Apelação n. 0019906-40.2012.8.26.0071, rel. Julio Caio Farto Salles, j. 11/12/2014) (g.n.).

Neste interim, o pedido da Defesa para desclassificação para o crime do artigo 28 da lei de Drogas não merece acolhida, eis que nada há nos autos que indique serem os réus usuários de drogas. Ademais, tal alegação, por si só, não retira a convicção de que também traficariam. Prova do alegado vício era ônus que lhes pertencia do qual, porém, não se desincumbiram. Além do mais, pode coexistir, na mesma pessoa, a figura de traficante e usuário. O fato de ser usuário de substância entorpecente não obsta ao reconhecimento da figura de traficante. Ao contrário, é natural que ambas as condições, a de usuário e a de traficante coexistam, pois, com a arrecadação obtida com a venda do entorpecente, possibilitar-se-á o emprego na

compra, para que o vício possa ser sustentado. Neste sentido, decisão da E. Corte Bandeirante:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Impetração visando a absolvição pela fragilidade probatória Pedido final de desclassificação ou substituição da pena. IMPOSSIBILIDADE. Presentes a autoria e a materialidade - Reconhecimento do tráfico pelas circunstâncias da ocorrência - Usuário também pode ser traficante Guardas civis que visualizaram o momento em que o apelante jogou as drogas ao chão Inviável o aumento da redução e a substituição da pena - Recurso não provido. TJ-SP - Apelação: APL 00000372620128260125 SP 0000037-26.2012.8.26.0125. Julgamento:12/08/2014 (grifo nosso)

De outra feita, a defesa não explicou e não logrou refutar as assertivas minuciosas dos depoentes e não arrolou testemunhas que amparassem suas ressalvas. Não indicou motivos concretos e plausíveis para falsa incriminação. Não demonstrou vício no flagrante e no resultado da persecução. Assim, o contexto fático revela, de maneira indubitosa, que os réus praticavam o comércio de entorpecente, sendo de rigor a condenação.

Diante do exposto, por esses fundamentos e mais o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO os réus HENDINER LUIZ CORREA e MARCELO BUENO DA SILVA, , já qualificados nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 c.c. artigo 29, "caput", do Código Penal. Resta dosar a pena pelo critério trifásico adotado pelo Código Penal. Em relação ao réu Hendiner Luiz, na primeira fase da dosimetria da pena, atento aos elementos preconizados pelo artigo 42 da Lei 11.343/06 c.c. 59 do Código Penal, bem como à primariedade do réu (F.A. e certidões a fls. 59/60), fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60). Na segunda fase, não estão presentes quaisquer das circunstâncias agravantes e/ou atenuantes. Na terceira fase, entendo que se faz necessário o reconhecimento da diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois o réu é primário e não há nos autos notícias de sua participação em associação criminosa. Assim, diminuo a pena anteriormente imposta entendendo que se faz necessário o reconhecimento da diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois o réu é primário e não há nos autos notícias de sua participação em associação criminosa ou de que esteja presente a habitualidade delitiva. Assim, diminuo a pena anteriormente imposta em 2/3 (dois terços) resultando em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. Não estão presentes mais causas de aumento ou de diminuição da pena. Portanto, fixo em definitivo a pena a cumprir de 01 (UM) ANO, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 194 (CENTO E NOVENTA E QUATRO) DIAS-MULTA, COM O DIA UNITÁRIO NO PISO MÍNIMO LEGAL.

Em relação ao réu Marcelo Bueno, na primeira fase da dosimetria da pena, atento aos elementos preconizados pelo artigo 42 da Lei 11.343/06 c.c. 59 do Código Penal, bem como aos antecedentes do réu (F.A. e certidões a fls. 61/65), verifico que a pena-base não merece exasperação vez que a conduta praticada não extrapola ao tipo penal em questão. Assim, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60). Na segunda fase, não estão presentes quaisquer das circunstâncias agravantes e/ou atenuantes. Na terceira fase, entendo que se faz necessário o reconhecimento da diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois, conquanto possua antecedentes criminais, não há nos autos notícias de sua participação em associação criminosa. Assim, diminuo a pena anteriormente imposta em 2/3 (dois terços) resultando em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. Não estão presentes mais causas de aumento ou de diminuição da pena. Portanto, fixo em definitivo a pena a cumprir de 01 (UM) ANO, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 194 (CENTO

E NOVENTA E QUATRO) DIAS-MULTA , COM O DIA UNITÁRIO NO PISO MÍNIMO LEGAL.

Pese contrário ao entendimento deste Magistrado, para ambos os réus, necessário apontar que o regime inicial deverá ser o ABERTO para ambos os réus, conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exarado no bojo do HC n. 596603-SP, no qual houve determinação para imposição de regime inicial aberto para cumprimento de pena, inclusive em relação a fatos futuros, na hipótese de condenação por tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal. Confira-se (...) Aos condenados que atualmente cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha - devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de cumprimento da pena. (STJ - HC: 596603 SP 2020/0170612-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04/08/2020).

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal - HC 118.533 - reconheceu que o delito em questão não é mais hediondo, entendo viável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Desta forma, faço a substituição da pena privativa de liberdade anteriormente fixada por duas restritivas de direitos. Assim sendo, observado o disposto pelo artigo 44, parágrafo 2º, 2ª parte e na forma dos artigos 45, parágrafo 1º e 46, todos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, a de Prestações de Serviços à Comunidade e de Prestação Pecuniária, por se revelarem as mais adequadas ao caso, sendo aquela consistente em tarefas gratuitas a serem desenvolvidas, pelo prazo da condenação, junto a entidade determinada pelo juízo da execução, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado, sem prejuízo da multa já fixada e a prestação pecuniária no valor de um terço do salário mínimo nacional da época da infração penal, sendo destinada para entidade beneficente também indicada pelo juízo das execuções penais.

Ao Juízo da Execução, após o trânsito em julgado desta decisão, caberá fiscalizar a entidade beneficiada com a prestação de serviços, a qual deverá ser comunicada a respeito, através de seu Representante, com remessa de cópia da presente sentença, incumbindo-lhe encaminhar mensalmente relatório circunstanciado, bem como a qualquer tempo, comunicar sobre a ausência ou falta disciplinar da condenada, consoante disposto pelo artigo 150 da Lei nº 7.210/84. Deverá, ainda, ser cientificado que a condenada é facultada cumprir a pena substitutiva em menor tempo (artigo 55 do Código Penal), sendo que, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada ou restante.

De acordo com o artigo 387, parágrafo único do CPP, inalterados os requisitos e não existindo prisão provisória decretada, já que fora substituída pelas medidas cautelares diversas da prisão, os réus poderão apelar em liberdade.

Conforme art. 63 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 91 do CP, decreto o perdimento de tudo quanto apreendido neste processo. Não tendo havido controvérsia, no curso do processo, sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente (Lei n. 11.343/06, arts. 33, §§ 1º e 2º, e 58, §1º), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, preservando-se fração suficiente para eventual contraprova. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente, caso isso ainda não tenha sido providenciado.

Após o trânsito em julgado desta decisão, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição da República, oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu, e providencie-se o necessário para o cumprimento da sanção penal imposta. Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias e efetuem-se as averbações de praxe (NSCGJ, Cap. V, itens 22, d, e 23). Custas processuais nos termos da lei.

P.I.C.

Avare, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA